

1500828-86.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... e encontravam-se em local cujo trafico é difundido. Nesse sentido: "Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público - Condenação. Cabível - Nulidade da apreensão realizada por guarda municipal - Não acolhida - Possibilidade da ação dos guardas municipais - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal e artigo 5º da Lei 13.022/14 - Aos guardas-civis, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500828-86.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162475/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25570307 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2162475 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

CAMILA APARECIDA TEODORO VALENÇA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP e Art. 35 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

26/08/2022

Réu Preso

Em 26 de agosto de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa da DR^a. FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DD^a. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, os réus CAMILA APARECIDA TEODORO VALENÇA e NIKOLAS DE LIMA, bem como os seus Defensores Técnicos, DR. Diego Augusto de Camargo OAB 331306/SP e DRA Dina Conceicao de Almeida Miranda OAB 70820/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Juceíl Batista Rodrigues (GCM) e Fernando Neves dos Santos (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de os acusados se entrevistarem reservadamente com os seus Defensores. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório dos réus. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do

Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. A ré CAMILA APARECIDA TEODORO VALENÇA, bem como o réu NIKOLAS DE LIMA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados criminalmente como incursos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, eis que: 1) no mês de junho de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico; e 2) em 14 de junho de 2022, por volta das 17h35, na rua Antônio Orlando Salmasi, altura do nº 486, Vila Vicente Correa, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 05 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 8,5 gramas e 14 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 8,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados - namorados - praticavam o tráfico na viela situada no bairro Rosa Garcia II, dividindo as tarefas na empreitada criminoso. Para tanto, NIKOLAS trazia porções de drogas em mãos, para facilitar as entregas aos interessados, enquanto CAMILA guardava parte do valor auferido, sendo que o restante permanecia escondido no muro de uma casa abandonada. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina quando receberam a informação de que CAMILA e NIKOLAS estavam fornecendo entorpecentes para os "vapores" revenderem. A informação ainda dava conta de que os denunciados guardavam o dinheiro no muro do imóvel. Os agentes públicos avistaram CAMILA e NIKOLAS ao lado da viela e procederam à abordagem. Em revista pessoal, no bolso da jaqueta de NIKOLAS foram encontradas 05 porções de "maconha" e 14 porções de cocaína, além de R\$24,90. Com CAMILA foram localizados R\$100,00 e aparelho de telefonia celular. No muro da casa foram encontrados R\$ 313,00. Notificados (fls. 105 e 107), os réus apresentaram Defesas Preliminares (fls. 115/120 e 124/128), procedendo-se, então, o regularmente recebimento da denúncia em 18 de agosto de 2022 (fls. 132/134). Durante a instrução, os réus foram interrogados, bem como foram ouvidas duas testemunhas, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos réus nos termos da exordial. Por outro lado, as Defesas Técnicas dos réus pugnaram pela total absolvição dos acusados, sustentando falta de provas, bem como, subsidiariamente, desclassificação delitiva ou, em caso de condenação pelos crimes imputados na exordial, pela aplicação de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em fase de dosimetria da pena e fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 34/35 e 39/41, bem como certidões a fls. 33 e 36/38. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Da preliminar de nulidade decorrente da atuação da guarda civil municipal. Aduz a defesa amparada em julgado da lavra do E. STJ que os agentes da guarda civil municipal não tem legitimidade para realização de busca pessoal. A despeito do julgado mencionado pela defesa, o entendimento dessa magistrada amparada em farta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é de que tais agentes públicos tem o dever de proceder a abordagem quando houve fundada suspeita, a fim de evitar a ocorrência do crime ou cessá-lo. In casu, recaía denúncia sobre os réus e encontravam-se em local cujo trafico é difundido. Nesse sentido: "Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público - Condenação. Cabível - Nulidade da apreensão realizada por guarda municipal - Não acolhida - Possibilidade da ação dos guardas municipais - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal e artigo 5º da Lei 13.022/14

- Aos guardas-civis, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a ocorrência de crime, tendo flagrado a ré em conduta clara e suspeita, em local conhecido pela prática do narcotráfico, sendo certo que a omissão dos agentes poderia levar à eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. Desnecessidade de critérios rígidos para realização de busca pessoal. A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que a apelada foi abordada e presa em situação de flagrante na via pública e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade ante a fundada suspeita de que estava na posse de objetos ilícitos circunstância que dispensa a necessidade de mandado conforme previsão expressa do artigo 244 do CPP e que se confirmou com a apreensão dos psicotrópicos. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos agentes da lei harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar a acusada. Os guardas municipais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. Negativa da ré restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar a ré da condenação. Prova da finalidade de entrega a terceiros advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. É certo que a prova da mercancia não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Pena-base mantida em seu patamar mínimo legal. Aplicada a causa de redução do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direitos - Inviável - Requisitos do benefício não foram satisfeitos. Regime inicial semiaberto. Regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade da autora. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1519489-12.2021.8.26.0228; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2022; Data de Registro: 24/08/2022). Assim não há que se falar em vício na abordagem realizada pelos guardas civis municipais, afastada a tese anulatória da defesa. Superada a preliminar arguida, o pedido acusatório merece ser julgado parcialmente procedente. Vejamos: É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas - de que trata o art. 29 do Código Penal - com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. (...) " (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Neste mesmo sentido, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...) " (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação,

de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)" (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, inexistem provas suficientes de os réus pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse mapeado com precisão as divisões de incumbências da suposta associação criminosa, bem como outras circunstâncias que evidenciariam que o tráfico não seria exercido pontualmente. Deste modo, é de rigor, pela ausência de provas, a absolvição dos acusados, no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto de constatação preliminar (fls. 14/15), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100) e pelas demais provas acostadas nos autos. A autoria é igualmente evidente e clara, a despeito dos acusados terem negado peremptoriamente a prática dos fatos. Senão vejamos: O réu, em solo policial (fls. 06), afirmou que é namorado de CAMILA e que, na data dos fatos, estavam conversando sobre a relação. Então, uma viatura da GCM chegou ao local e abordou-os. Os GCM's não encontraram nenhum entorpecente om o casal, somente encontraram uma pequena quantidade de dinheiro com o interrogado, menos de R\$ 20,00. Os GCM's, no local, não lhe mostraram nenhum entorpecente. Somente mostraram o entorpecente apreendido quando chegaram a unidade policial. Negou que estivesse no local traficando. Em juízo, disse que tudo o que foi dito pelos policiais e mentira. Tem um filho de 5 meses com Camila e ela esta grávida novamente. Não foi encontrado nenhum entorpecente com ele, apenas estava com R\$20,00. Trabalha terceirizado e ganha R\$30,00 por período. Pegou o dinheiro, foi encontrar Camila, comprou uma cerveja e começaram a discutir, até achou que a viatura se aproximou por causa da discussão. Quando foi abordado pediu para alguém filmar, pois os guardas fazem abordagens irregulares. Na delegacia não sabia o que estava acontecendo e só depois lhe disseram que ele estava sendo preso por tráfico e exibiram a droga. Disse que a droga não era sua, que tinha acabado de chegar no local. Já conhecia os GCMs e há um tempo eles vinham dizendo que iriam pegá-lo. Não correu deles porque não estava devendo nada e para ver Camila ia até lá, mas não entrava na casa dele, pois não tem um relacionamento tão próximo de sua sogra para ficar na casa dela ou comer lá. Já foi até agredido pelos guardas. Camila estava com dinheiro do seu trabalho de cabeleireiro. Não sabe onde é esse local que eles encontraram o dinheiro e nem os viu encontrando. Ajudava um amigo seu a fazer cobrança de enxovais. Tem um filho e sua namorada está grávida. Já foi processado. Tinha bastante gente na rua, mas a abordagem foi muito rápida. Não sabe se alguém filmou ele sendo agredido pelos guardas. Tomou soco nas costas, na cabeça e o ameaçaram com spray de pimenta. Não sabe quem lhe agrediu, pois o empurraram e ficou de costas. Estavam há 50 metros do bar da mãe da Camila. Encontrou com Camila na rua. Por sua vez, a ré, em solo policial (fls. 05), manteve-se silente. Em juízo, negou os fatos. Trabalha, tem seus bicos para sustentar seus filhos e jamais faria isso. Estava do lado da sua casa quando foi abordado e conversava com Nikolas. Quando eles chegaram ficaram tranquilos, pois não estavam fazendo nada. Estava com o dinheiro do seu trabalho. Nikolas não tinha droga nenhuma. Os guardas foram muito agressivos com Nikolas e nem entendeu o motivo. Jogaram ele de costa e o algemaram e falavam que eles sabiam o motivo daquilo. O dinheiro estava em seu bolso. Não viu os policiais encontrarem esse valor. Não tem nada com os guardas, mas acredita que eles tenham algo contra Nikolas, pois eles têm amizade com todo mundo e os agentes acham que todo mundo que mora na viela é traficante. Eles sempre fazem essa abordagem, vão até o mato. Mora no bairro há 15 anos e tem amizade com toda população e não entende quem e o porquê fizeram essa denúncia. Sua mãe tem um comercio no bairro e conhece muita gente. Faz

bico de cabelereiro. Tem três filhos e está grávida. Nunca foi processada. Perguntas da acusação – sua mãe viu a abordagem e eles chegaram a ofender sua mãe que estava com sua filha de 4 anos. Viu que chutaram Nikolas e o colocaram na viatura. Ele ficou reclamando de dor no corpo. É usuária de maconha. Analisando a autodefesa do acusado e da ré – colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – observo que ambos negaram a prática criminosa. Contudo, não apresentaram justificativas convincentes, comprometendo a verossimilhança de seus relatos. Note-se que os réus alegaram que a droga foi forjada e o réu Nikolas agredido, sem que tenham produzido uma única prova nesse sentido. E mais, a prova dos autos afasta completamente a narrativa defensiva, revelando a prática do crime de tráfico de drogas. De fato, o Guarda Civil Municipal Fernando Neves dos Santos, em sede policial (fls. 02/03), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento pelo Bairro Rosa Garcia II, momento em que foram acionados por um morador, o qual informou a equipe policial que no local do fato, ao lado de uma viela, um indivíduo de nome Nikolas, acompanhado de sua namorada, estariam entregando kits de drogas para "vapores", bem como também arrecadando o dinheiro das vendas dos entorpecentes, sendo que a quantia era guardada em um muro de uma casa, a qual está abandonada, entre os "balaústres". De posse das informações, foram até o local indicado da "denúncia" e, lá, avistaram o casal ao lado da viela. Foram abordados e, em revista pessoal, foi localizado no bolso da jaqueta de NIKOLAS, 01 kit de maconha aberto, a qual continha 5 porções, um kit fechado de pinos de cocaína, a qual continha 14 pinos da substância, além da importância de R\$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos). Já com a sua namorada, CAMILA, foi encontrada a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em notas diversas e mais um aparelho celular. Na sequência, foi verificado o que continha no muro com os "balaústres", sendo localizada a quantia de R\$ 313,00 (trezentos e treze reais). Indagados sobre as drogas e o dinheiro, negaram a traficância. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento pelo bairro e foram informados que os réus estariam realizado o tráfico e que Nikolas estaria fazendo a entrega dos entorpecentes para os "vapores". Foram até o local onde fica a viela, visualizaram os réus e com o acusado foram encontrados os entorpecentes e com a ré dinheiro. Tinham denúncias anteriores também, mas quando abordavam o réu, apenas dinheiro era encontrado. A denúncia recaía sobre o casal – Nikolas e sua namorada Camila. Não conhecia o morador que fez essa denúncia e foi abordado por ele na rua. O réu passou o endereço de onde residia e a Camila morava com a mãe, ao lado da viela onde foram abordados. O dinheiro foi encontrado na mesma rua que estavam os réus, no muro de uma casa abandonada. Não pegaram os dados desse morador, apenas foram verificar a denúncia que ele forneceu. Constantemente moradores fazem denuncia, com o fim de tirar os traficantes do bairro. O local é muito movimentado, mas na ocasião ao lado da viela estavam apenas os réus. Ambos negaram a prática do tráfico. O réu chegou a resistir a prisão e instigou a namorada a incitar a população contra a viatura. Camila nada disse acerca do dinheiro. O denunciante informou que o dinheiro estava guardado no balaústre da casa abandonada. Os réus não aparentavam estar sob efeito de substância entorpecente. Convergingo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Juceil Batista Rodrigues, em sede policial (fls. 04), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, disse que já conhecia o acusado de abordagens anteriores e a Camila que era namorada de Nikolas e morava ao lado da viela. Tinham informações de que o casal estava realizando a traficância no bairro. Estavam em patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia, quando um morador chamou a viatura e disse que um casal, sendo este Nikolas e sua namorada e que entregavam kits para os vendedores. A namorada fazia também a distribuição dos entorpecentes e guardava o dinheiro e que guardava o dinheiro no balaústre de uma casa abandonada. O local que é famosa viela do bairro, costuma ter alto índice de traficância. O casal estava junto e ao lado da viela. Vieram pelo lado contrario da rua Antonio Orlando Salmasi e os réus mostraram-se surpresos com a presença da viatura e ficavam parados. Com Nikolas foram encontradas porções de maconha e um kit contendo 14 pinos de cocaína, cerca de R\$14,00 e com Camila foi encontrado R\$100,00 em notas diversas. Após revistarem os réus, seu parceiro se

deslocou até a casa abandonada e localizou cerca de R\$300,00 em dinheiro. Perguntas da defesa – Nikolas num primeiro momento ficou estático e depois que encontraram o entorpecente, o réu apresentou certa resistência e foi necessário uso de força. Em relação a Camília, o depoente não a tinha abordado. Camila sempre é vista naquele local. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente os réus ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos guardas, que narraram, verossimilmente, a apreensão das drogas com o acusado, com a ré dinheiro e outro numerário escondido num muro e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 3) a exata correspondência das características e nomes dos traficantes apontados em delação anônima, com a do réu, verificado durante a diligência policial; e 4) a forma de embalagem da droga, em pequenas porções, própria da venda “a varejo”, confirmando a destinação comercial da droga. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de

tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, aprendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbis gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 98/100) e demonstrado que os réus incorreram em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo, guardar e ter em depósito –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que os réus perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. I – DO RÉU NIKOLAS: Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, já que se trata de réu reincidente. No entanto, como tal circunstância será apreciada em segunda fase, por ora, . Por tal razão, fixo sua pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, tratando-se de réu reincidente (Processo nº 0000413-56.2017.8.26.0571, fls. 36), agravo sua pena em 1/6, gerando a reprimenda legal de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da incidência da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim,

imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice, na medida em que se cuida de réu reincidente, não preenchendo os requisitos subjetivos cumulativos exigidos pela norma em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, e art. 59, inciso III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando se tratar de réu reincidente, o que denota que a modalidade prisional mais severa é necessária e a única suficiente à devida reprovação e prevenção do ilícito, bem como para a eficaz ressocialização do réu. A mesma motivação acima exposta impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). II – DA RÉ CAMILA: Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis à ré, motivo pela qual fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes agravantes ou atenuantes a incidir, mantenho sua pena inalterada em sua fase. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da incidência da agravante do estado de calamidade pública pelas mesmas motivações acima expostas. Na terceira etapa, presentes os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e o regime aberto para cumprimento da pena. Presentes os requisitos legais substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistente em prestação de serviço a comunidade na razão de uma hora por dia de condenação e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. III – DO DISPOSITIVO E DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para: 1) condenar o réu NIKOLAS DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; 2) condenar a ré CAMILA APARECIDA TEODORO VALENÇA, devidamente qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, com valor unitário no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito

consistentes em prestação de serviço a comunidade na razão de uma hora por dia de condenação e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e 3) absolver os réus da imputação de infringência ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, considerando que se trata de réu reincidente, verifica-se que, solto, o réu certamente tornará a delinquir. Por tal razão, para garantir a ordem pública, deve ser mantida a segregação cautelar dele em caso de recurso. Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. De outro lado, quanto à ré, inalterada as razões que permitiram responder a esse feito solta (fls. 49/54) e substituída sua pena, defiro o Apelo em Liberdade. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor da ré, bem como guia de recolhimento quanto a ambos, bem como arquivem-se os autos. Isentos os acusados do pagamento das custas processuais, concedendo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que foram assistidos nos autos por defensor dativo. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se os réus para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 82) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 437,90 em dinheiro - fls. 74) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP". Pelos Defensores dos réus e pelos réus foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo os recursos interpostos pelos réus, saindo os Defensores, desde já, intimados a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeçam-se as competentes certidões de honorários (fls. 108/109). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA